

1505201-45.2021.8.26.0362

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PAULO ROGERIO MALVEZZI

Comarca: Mogi-Guaçu

Foro: Foro de Mogi Guaçu

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/02/2022

... de que o acusado realmente se dedicava ao tráfico, em razão da quantidade de entorpecente apreendido e forma como a droga estava embalada, características típicas do tráfico varejista.

Ademais, o acusado confessou que comercializava drogas no local, de modo que a autoria resta incontestada.

Bem de ver que o tipo penal descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06 é misto ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Guaçu

Foro de Mogi Guaçu

Vara Criminal

Rua José Colombo, 45, Mogi Guacu - SP - cep 13840-065

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1505201-45.2021.8.26.0362 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505201-45.2021.8.26.0362

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO SOUSA OLIVEIRA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO ROGERIO MALVEZZI

Vistos.

Fernando Sousa Oliveira foi denunciado e está sendo processado, porque no dia 08 de agosto de 2021, por volta das 15h30min, na Rua Marli Aparecida Leme, nº 44, nesta cidade e comarca de Mogi Guaçu, agindo com dolo determinado, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, trazia consigo, para fins de narcotráfico/entrega a consumo de terceiros, 02 (duas) pequenas embalagens contendo a droga cocaína, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, de uso proscrito no Brasil (conforme Portaria nº 344/98 e atualizações posteriores da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde).

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas no parágrafo anterior, Fernando Sousa Oliveira, agindo com dolo determinado, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar tinha em depósito e guardava, para fins de narcotráfico/entrega a consumo de terceiros, 10 (dez) pedras da droga "crack" (feita com cocaína), 31 (trinta e uma) porções da droga Cannabis sativa, 10 (dez) porções da droga MDMB-4en-PINACA (canabinoide sintético), 11 (onze) embalagens contendo a droga cocaína, 06 (seis) porções da droga haxixe, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica,

de uso proscrito no Brasil (conforme Portaria nº 344/98 e atualizações posteriores da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde).

O acusado foi notificado (fls. 149), apresentou defesa prévia (fls. 140/141) e a denúncia foi recebida (fls. 150/152).

O acusado foi citado (fls. 215).

Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas e o réu foi interrogado.

O representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal e condenação do acusado nos termos descritos pela denúncia.

A defesa requer seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea e sua compensação com a agravante da reincidência. Requer seja reconhecida a semi-imputabilidade do agente, nos termos do artigo 26, § 1º, do Código Penal. Pretende que seja afastada a causa de aumento de pena descrita pelo artigo 40, III, da lei n. 11.343/06. Requer seja reconhecida o bis in idem entre os maus antecedentes e a reincidência.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

No mérito, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 15/16); pelo auto de constatação provisória de substância tóxica (fls. 17/18), pelo laudo pericial do local (fls. 92/96); pelo laudo pericial toxicológico (fls. 80/82; 83/85; 86/88 e 89/91) e por toda a prova oral colhida em juízo.

O guarda municipal Adaniere Marinho Gois disse que recebeu informações de que indivíduo trajando camisa cinza estaria praticando tráfico no Jardim dos Lagos. Avistou indivíduo mexendo em uma moita. Realizada a busca pessoal, localizou 2 papalotes e dinheiro. Na moita onde ele estava mexendo, apreendeu mais drogas, mas não se recorda a quantidade. Não notou que o acusado tivesse aparência debilitada pelo consumo de drogas.

O guarda municipal Marcos Felipe Salvador Leandro prestou depoimento no mesmo sentido de seu colega de farda, confirmando que se deparou com o acusado agachado em uma moita. Disse que foi o responsável por apreender as porções durante a busca pessoal. Informa que as drogas localizadas pelo cão estavam próximas à margem do lago.

Em solo policial, o acusado Fernando Sousa Oliveira disse que havia vendido um "kit" com quinze porções de cocaína e ficou com duas porções, que são aquelas apreendidas em seu poder. O dinheiro apreendido lhe foi entregue por sua genitora. Não era o proprietário das demais drogas apreendidas (fls. 09).

Em juízo, o acusado disse que era usuário de 'crack' e possuía 15 porções de cocaína destinadas à comercialização. Em troca da comercialização dessas porções, receberia porções de crack, e não dinheiro. Sabia que no local ocorria a venda de drogas de outras espécies, mas não pelo interrogando, e sim por outras pessoas. Disse que havia outras pessoas pelas imediações.

Com efeito, o depoimento prestado pelos guardas municipais é digno de toda credibilidade, já que devidamente compromissados e inexistentes indícios de interesse dos servidores públicos em prejudicar pessoa inocente. De acordo com a jurisprudência:

PROVA - Depoimento policial - Eficácia - Mera condição de agente público que não torna a testemunha impedida ou suspeita - Precedentes - Recurso improvido.

(Apelação Criminal n. 974.712-3/9-00 - Santos - 14ª Câmara Criminal - Relator: Sérgio Ribas - 01.03.2007 - V.U. - Voto n. 4.191).

PROVA - Depoimento policial - Valor - Credibilidade e responsabilidade equivalentes à palavra dos civis, máxime quando corroboradas pelo conjunto probatório -

Precedentes - Recurso improvido. (Apelação Criminal n. 497.707-3/9-00 - Santos - 5ª Câmara Criminal - Relator: Marcos Zanuzzi - 01.03.2007 - V.U. - Voto n. 13.332).

Importante frisar que não há que se duvidar do relato dos guardas municipais na medida em que o próprio acusado disse que não tinha nada contra os agentes, de modo que não se vislumbra nenhum indício para imputarem falsamente o crime ao acusado.

No caso dos autos, as provas carreadas permitem a formação da convicção de que o acusado realmente se dedicava ao tráfico, em razão da quantidade de entorpecente apreendido e forma como a droga estava embalada, características típicas do tráfico

varejista.

Ademais, o acusado confessou que comercializava drogas no local, de modo que a autoria resta inconteste.

Bem de ver que o tipo penal descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06 é misto alternativo, de modo que, comprovado que o acusado trazia consigo e guardava quantidade expressiva de droga acondicionada de forma fracionada, deve ser dado como incurso naquele preceito legal. A esse respeito:

"O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente" (RT 776/663). "Ademais, é sabido que o tráfico de entorpecentes é delito de ação múltipla ou conteúdo variado cuja consumação se contenta com a aquisição, transporte, depósito, guarda ou simples porte da droga, desde que não seja para consumo pessoal. Daí não haver falar em mero auxílio ao uso de drogas, visto que a paciente foi flagrada na posse de maconha e cocaína. (STJ, HC 211.467/DF, Rel. Min. OG FERNANDES, 6ª TURMA, julgado em 16/08/2011, DJe 31/08/2011).

Nem se diga pela semi-imputabilidade do agente, pois seu reconhecimento demanda início de prova documental para instauração do respectivo incidente de dependência química, o que está ausente nos autos.

Por estes fundamentos, a condenação é medida de rigor.

Passo à dosagem da pena, em conformidade com o disposto nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

Em primeira fase, fixo a pena privativa de liberdade acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes, já que ostenta condenação transitada em julgado nos autos n. 00000009-31.2009 (fls. 165).

Nesse cenário, fixo a pena privativa de liberdade em 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

Em segunda fase, estão presentes a agravante da reincidência (autos nº 0000205-21.2015 - fls. 165/166) e a atenuante da confissão espontânea, sendo que a primeira prevalece sobre esta última, nos termos do art. 67 do Código Penal: no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. Bem por isso a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal decidiu que:

Habeas Corpus substitutivo de recurso ordinário. Roubo circunstanciado. Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Impossibilidade 1. O acórdão impugnado está em conformidade com a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, a teor do art. 67 do Código Penal, "a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada" (RHC 110.727, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual (HC 105.543/MS, Relator Min. Roberto Barroso, julgado aos 29/4/2014)

"a confissão espontânea é ato posterior ao cometimento do crime e não tem nenhuma relação com ele, mas, tão somente, com o interesse pessoal e a conveniência do réu durante o desenvolvimento do processo penal, motivo pelo qual não se inclui no caráter subjetivo dos motivos determinantes do crime ou na personalidade do agente" (HC 102.486, Rel. Min. Cármen Lúcia)" (STF, HC 113.780/MG, Relator Ministro Roberto Barroso, DJe 20-4-2018).

Anoto que, em se tratando de reincidência específica pelo cometimento do crime de tráfico de drogas, o entendimento deste Magistrado seria o de majorar a pena além da fração de 1/6.

No entanto, como forma de prestigiar a confissão espontânea, aplico a fração de 1/6, resultando pena privativa de liberdade de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 680 dias multa.

Nesse ponto, deve-se destacar que o reconhecimento de maus antecedentes, na primeira etapa da fixação, e da reincidência, na segunda, quando fundamentada em

processos distintos, não ocasiona o bis in idem.

De acordo com Guilherme de Souza Nucci: Justamente porque o critério eleito pela lei penal é o trifásico, e sabendo-se que as circunstâncias judiciais podem confundir-se com as legais (maus antecedentes – circunstância judicial – e reincidência – circunstância legal), deve o magistrado agir com redobrada cautela. Entretanto, quando houver o estabelecimento de duas situações distintas, dando azo à aplicação, também distinta, de circunstâncias judiciais e legais, é possível a dupla agravação. Nesse sentido: STF: “Maus antecedentes por uma condenação e reincidência por outra não faz bis in idem” (HC 73.289/SP, 1ª Turma, relator Min. Moreira Alves, 28/11/95, v.u.). E ainda: STJ: “O método trifásico não impede que, na fixação da pena-base, seja ultrapassado o mínimo legal previsto, com base nos antecedentes do réu, demonstrativos de não ser o crime um fato episódico em sua vida (indiciamento em inquérito, denúncia por infrações várias etc). Já a reincidência, considerada na segunda operação, funciona como agravante porque já fora ele (acusado) denunciado e condenado irrecorrivelmente por estelionato em dois processos. Nestas hipóteses, não há falar-se em bis in idem” (HC 8.817/MS, 6ª Turma, Relator Ministro Fernando Gonçalves, 3/8/1999, v.u.).

O Supremo Tribunal Federal decidiu também que: Maus Antecedentes e Reincidência: “Non Bis in Idem” - A utilização de condenações distintas e com trânsito em julgado, para fins de aumento de pena por maus antecedentes e reincidência, não viola o princípio do non bis in idem. Com base nesse entendimento, a Turma indeferiu habeas corpus nos quais se pleiteava a redução das penas impostas aos pacientes, com o afastamento da exasperação relativa aos antecedentes desabonadores. Inicialmente, registrou-se não se estar diante do mesmo tema que se encontra pendente de julgamento pelo Plenário da Corte concernente à possibilidade de reconhecimento de inquéritos policiais e ações penais em curso como maus antecedentes. Em seguida, reputou-se razoável que – no caso de diferentes condenações pretéritas com trânsito em julgado – uma delas fosse utilizada para caracterizar os maus antecedentes (CP, art. 59), na fixação da pena-base, e outra, para considerar a reincidência, como agravante, na segunda fase da dosimetria penal (CP, art. 61, I). Precedentes citados: HC 99044/SP (DJE de 21.5.2010); HC 94846/RS (DJE de 24.10.2008). HC 96771/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, 17.8.2010. (HC-96771)

HC 101832/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, 17.8.2010. (HC-101832)

HC 96961/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, 17.8.2010. (HC-96961).

Em terceira fase, incide também a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/06, já que o fato ocorreu em local especialmente protegido, tratando-se de área destinada a recreações de qualquer natureza (Jardim dos Lagos/Pedalinho) o que evidentemente facilita a propagação do tráfico de drogas. Aliás, a lei não exige que aquele seja o local especialmente visado pelo infrator, bastando a proximidade física. A esse respeito:

A traficância era exercida em local inequivocamente próximo das escolas “Zumira” e “Rubens Leme Asprino” (distava aproximadamente 800 metros da primeira e 490 metros da segunda - vide fls. 74/7), sendo que para a incidência da majorante referente ao artigo 40, inciso III, não exige a lei que o estabelecimento de ensino seja especialmente visado pelo infrator, bastando, tão somente, a proximidade física e o conhecimento dessa proximidade. (TJSP, Apelação n. 0004114-44.2011.8.26.0083, Relator Des. Geraldo Wohlers, julgado aos 26.2.2013, 3ª Câmara de Direito Criminal).

Ainda sobre essa questão, o Col. Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se pronunciar no sentido de que “(...) O tráfico de drogas nas imediações de estabelecimentos de ensino é suficiente para incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, independente de os agentes visarem ou não os frequentadores daquele local (...). Destarte, não procede a alegação da impetrante no sentido de que não há demonstrativo de relação evidente entre a conduta dos pacientes e as atividades desenvolvidas pelos estabelecimentos ensino, uma vez que é irrelevante o fato de haver ou não intenção dos acusados de atingir os frequentadores do estabelecimento. Para incidência da mencionada causa de aumento de pena, basta a proximidade física do local onde o tráfico estava sendo

praticado e o estabelecimento de ensino, o que ficou corretamente assentado pelas instâncias ordinárias." (HC 116.929/SP, 1ª Turma, relator Min. Luiz Fux, julgado aos 15.10.2013).

No mesmo sentido, posiciona-se o E. Superior Tribunal de Justiça, que em precedente desta Comarca decidiu que: No entanto, o Superior Tribunal de Justiça possuía entendimento no sentido de ser desnecessária, para a incidência da majorante do artigo 40, III, da lei de drogas, a comprovação de que o comércio de ilícito de substâncias entorpecentes vise atingir os alunos do estabelecimento, bastando, para sua incidência, que a prática da traficância tenha ocorrido nas imediações da escola (RESP n. 1.774.414/SP, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 22.2.2019).

Assim, majoro a pena em 1/6, do que resulta pena privativa de liberdade de 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão e o pagamento de 793 dias-multa.

Ainda em terceira fase, inviável a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, em razão dos maus antecedentes do agente.

Cada dia-multa será calculado no mínimo legal.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicialmente FECHADO, pois o acusado é reincidente específico.

Inviável a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão do total da pena imposta.

Por estas razões, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO Fernando Sousa Oliveira à pena privativa de liberdade de 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 793 dias-multa, cada qual no mínimo legal, dando-o como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, III, da Lei nº 11.343/06.

O réu respondeu ao processo no cárcere e com a condenação ficam reforçados os fundamentos que ensejaram a custódia cautelar, razão pela qual lhe nego o direito de recorrer em liberdade, destacando que o acusado ostenta condenações anteriores com trânsito em julgado, sendo reincidente específico, o que demonstra que sua liberdade configura risco concreto à ordem pública. Recomende-se na prisão, com expedição de ofício.

Deixo de aplicar o quanto disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, pois o acusado não atingiu o lapso temporal para eventual progressão de regime.

Decreto o perdimento do numerário apreendido, pois consequência lógica da condenação imposta, destacando-se que o acusado não logrou demonstrar exercício de labor lícito. Oficie-se após o trânsito em julgado.

Expeça-se certidão de honorários ao patrono dativo inicialmente nomeado nos autos.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

PRI.

Mogi Guacu, 18 de fevereiro de 2022.

Paulo Rogério Malvezzi
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA